

1524152-04.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Penal, que não tem aplicação aos crimes tratados na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais. O tráfico é crime hediondo, que compromete a saúde pública, e a medida não se mostra socialmente recomendável.

Nesse sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524152-04.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524152-04.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILTON SANTOS DE LIMA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

WILTON SANTOS DE LIMA, VICTOR MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA, DAVI TEODORO CARDOSO, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, EMERSON DA SILVA e KHEDENSON HENRIQUE ROQUE HONORIO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, porque no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 15h30min, no interior de uma residência situada na Estrada Jose Lopes, defronte ao numeral 466, Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Paulo, associados entre si para a prática do tráfico de drogas, transportavam, guardavam e tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros: 01 invólucro plástico, contendo, aproximadamente, 926,8g de Cocaína; 48 frascos plásticos contendo, aproximadamente, 96,4g de Tetrahydrocannabinol, na

forma de 'Skunk';
278 microtubos plásticos contendo, aproximadamente, 267,9g de cocaína;
01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 197,5g de cocaína;
01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 125,7g de Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha;
64 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 410,4g de maconha;
1131 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 620,9g de cocaína e
01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 39,8g de cocaína na forma de 'crack', sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Notificados nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, os acusados apresentaram as respectivas defesas.

Recebida a denúncia, realizada audiência de instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se ao final os réus.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos termos da denúncia.

Os Drs. Defensores, por sua vez, levantaram preliminares de nulidade. Por primeiro, diante a ilegalidade da invasão domiciliar, bem como pela inépcia da denúncia. No mérito, pugnaram pela absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Subsidiariamente, requereram: fixação da pena base no mínimo legal; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; o afastamento da agravante referente à prática de delito durante estado de calamidade pública; o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em relação a Khedenson; fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, seja assegurado aos réus o direito ao recurso em liberdade. Os autos forma remetidos ao Ministério Público, que ofereceu manifestação pelo afastamento das preliminares levantadas (págs. 609/610).

É o relatório.

D E C I D O.

Por primeiro, afasto as preliminares de nulidade suscitadas pelos ilustres Drs. Defensores.

Não há que se falar em ilicitude da prova produzida.

É certo que as hipóteses permissivas de violação domiciliar possuem caráter de excepcionalidade absoluta e taxativa.

O texto constitucional preceitua que : "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).

Os policiais civis, nas oportunidades em que foram inquiridos, detalharam a dinâmica da diligência que realizaram e revelaram a fundada suspeita que motivou terem ingressado no imóvel referido na denúncia.

Afirmaram que receberam denúncia de que o tal imóvel seria local conhecido por "casa bomba". Foram averiguar e realizaram campana por alguns minutos. Viram quando dois indivíduos saíram da casa - WILTON e EMERSON - e os abordaram do lado de fora do imóvel, oportunidade em que ambos admitiram que no local havia drogas e que eram funcionários do tráfico.

Havia, portanto, fundadas razões da situação de flagrante delito naquele imóvel, o que justificou o ingresso dos policiais sem autorização judicial. Consentimento do morador não se poderia esperar, já que, ao que tudo indica, o imóvel era utilizado apenas para a mercancia.

Diante da confirmação da veracidade da denúncia que receberam pelos indivíduos abordados do lado de fora, dirigiram-se e entraram no imóvel apontado, oportunidade em que localizaram os corréus - VICTOR, DAVI, PAULO e KHEDENSON embalando as drogas.

Logo, o que se verifica é que diante da notícia que receberam de que o local seria verdadeiro depósito para preparação e embalagem de drogas - FUNDADA SUSPEITA - realizaram campana, abordaram os réus WILSON e EMERSON que viram saindo da casa, oportunidade em que ambos confirmaram a veracidade da denúncia que

estavam averiguando, justificando-se, assim, o ingresso no imóvel, local onde localizaram enorme quantidade de substâncias entorpecentes, crime permanente. Ora, como é sabido, a própria Constituição Federal autoriza a violação do domicílio nos casos de flagrante delito no interior da residência, exatamente o que ocorreu no crime aqui tratado.

E o Código Penal, em seu artigo 150, parágrafo 3º, inciso II, dispõe que não constitui crime de violação de domicílio a entrada ou permanência em casa alheia ou sua dependências a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime estiver sendo praticado no local.

As circunstâncias do caso concreto motivaram e justificaram o ingresso dos policiais no imóvel.

Nesse sentido : "Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do traficante, em sua residência, durante o período noturno, não constitui prova ilícita. Desnecessidade de prévio mandado de busca e apreensão. HC indeferido " (STF, 2ª Turma, HC 84.772/MG, relatora Ministra Ellen Graice, DJ 12/11/2004 p. 41). "A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio admite exceções, não protegendo o indivíduo em atividade criminosa no recesso da habitação. Em se tratando de tráfico de entorpecentes, delito de natureza permanente, a ausência da autoridade ou a falta do respectivo mandado, não maculam a busca e apreensão, inocorrendo, igualmente, nulidade da prisão em flagrante (TJSP - HC 68.215-3 - Rel. Diwaldo Sampaio - RJTJSP 115/257).

Desta forma, manifesta a situação flagrancial, a permitir a entrada dos agentes da lei no imóvel, não havendo, assim, afronta à Constituição Federal, à legislação ordinária (artigo 240 do CPP), ou ao Tema 280 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de forma que não há nulidade a ser declarada e muito menos prova ilícita.

Por fim, pelo que se apurou no contraditório, não houve violação do domicílio de quem quer que seja, uma vez que o imóvel era destinado apenas a atividade ilícita aqui tratada - casa bomba -, já que ninguém residia no local, de forma que não se tratava de residência.

Também não há que se falar em inépcia da denúncia.

A inicial acusatória descreveu a conduta criminosa com todas as suas circunstâncias, nos precisos termos do que estabelece o artigo 41 do Código de Processo Penal, o que possibilitou aos réus o exercício da ampla defesa. Ademais, trata-se de matéria já superada e preclusa. A denúncia já foi recebida e da referida decisão não sobreveio qualquer impugnação pelas partes no tempo oportuno. Não há o vício sustentado pelo ilustre Dr. Defensor do acusado Emerson, em razão da ausência de assinaturas das peças que instruíram o inquérito policial.

Com efeito, o Comunicado nº 2167/2017, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, instituiu as regras acerca da tramitação do inquérito policial eletrônico e especificou, com clareza, em seu inciso "4", alínea "a", das "REGRAS DE PROCESSAMENTO" que: "os termos de oitivas e interrogatórios da fase policial serão assinados digitalmente pela Autoridade Policial e os termos físicos assinados por todos permanecerão na Delegacia de Polícia podendo ser solicitados a qualquer tempo". E o inquérito policial eletrônico encontra respaldo, também, na lei federal nº 11.4129, de 19 de dezembro de 2006, que trata da informatização do processo judicial.

Ademais, é certo que não houve qualquer demonstração de efetivo prejuízo suportado pelos acusados, obstando, por consequência, o reconhecimento de inépcia da denúncia porque estaria esta calcada em cópias dos documentos originais do inquérito policial.

Por fim, de se ressaltar que eventual irregularidade ocorrida em sede de inquérito policial - procedimento investigatório - não macula a ação penal dele proveniente, uma vez que esta é realizada em contraditório pleno.

Assim, não se pode falar em nulidade ocorrida na fase inquisitorial, por se tratar de procedimento de caráter preliminar e informativo, cujos vícios são considerados meras irregularidades, que não afetam a ulterior ação penal que nele porventura se basear.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, FLAGRANTEFORJADO E ILEGAL OU REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS - IMPOSSIBILIDADE -

FLAGRANTES REGULARES, A INICIAL NÃO É INEPTA E EVENTUAL MÁCULA DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO VICIA A AÇÃO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS - NADA A RETIRAR CREDIBILIDADE DOS RELATOS POLICIAIS QUE REALIZARAMAS DILIGÊNCIAS BEM SUCEDIDAS - DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA - LOCAL USADO COMO PONTO DE EMBALAGEM E VENDA DE DROGAS - CAPTAÇÃO FORTUITA DE COMUNICAÇÃO COM OUTRO TRAFICANTE, O QUE PERMITIU NOVO FLAGRANTE - CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS PENASDOSADAS COM CRITÉRIO - O TRÁFICO EM PONTO TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A REINCIDÊNCIA DE KAIQUE E JULIANE, A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO ("CRACK")JUSTIFICAM AS REPRIMENDAS IMPOSTAS REGIME ADEQUADO - RECURSOS DESPROVIDOS". (Relator(a): Euvaldo Chaib; Comarca: Olímpia; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/02/2017; Data de registro: 16/02/2017).

"Habeas corpus visando desconstituição da prisão preventiva. 1. Circunstâncias a indicar que a custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública. 2. Não configuração, observados os limites do "habeas corpus", de irregularidades no inquérito policial. De toda sorte, como se sabe, eventual vício no inquérito policial não contamina a ação penal. Ordem denegada". (Relator(a): Laerte Marrone; Comarca: Panorama; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/01/2017; Data de registro:30/01/2017).

No mérito, a ação penal procede integralmente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 06 e seguintes); boletins de ocorrência (págs. 08/13, 79/81 e 82/85); auto de exibição e apreensão (págs. 31/33); laudo de constatação (págs. 71/76); exame químico-toxicológico encartado às págs. 478/482, que resultou positivo para tetraidrocanabinol e cocaína; bem como pela prova oral coligida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, ao que consta, por ocasião da prisão em flagrante, ainda no local da abordagem, os acusados confessaram informalmente aos policiais que eram responsáveis pelo tráfico de drogas naquele local, esclarecendo com minúcias a função de cada um deles no comércio espúrio.

Já na delegacia de polícia, perante a DD. Autoridade Policial, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, ficaram em silêncio.

Em Juízo, com exceção de KHEDENSON, todos negaram o cometimento do crime.

KHEDERSON narrou que à época enfrentava dificuldades financeiras, dirigiu-se ao ponto de venda de drogas para adquirir uma porção de maconha, destinada ao seu consumo e "...pedi pros menino deixar eu trabalhar um dia lá...".

Foi autorizado a vender as drogas no dia seguinte - segunda feira.

Desta forma, na manhã seguinte chegou por volta das 07h, "...peguei sim o cargo pra mim trabalhar lá e comecei vendendo...".

Por volta das 13h "...chegou uns três meninos lá pedindo maconha...", a essa altura já estava sem a droga, pediu pra que aguardassem, e se dirigiu a casa onde era armazenado o entorpecente.

Quando estava no interior do imóvel, foi surpreendido por dois policiais, que abriram a porta e se apresentaram, "...falando que eu tinha perdido...". Os policiais passaram a perguntar de arma, de drogas, de forma que apontou a eles o local onde o entorpecente era armazenado.

Esclareceu que foi orientado pelo traficante - "...o menino que estava trabalhando..." - a ficar com pouca quantidade de drogas na rua, e quando necessitasse deveria entrar no imóvel para buscar mais, uma vez que eram mantidas armazenadas em seu interior.

Informou que apenas VICTOR lhe pediu uma porção de maconha e estava acompanhado de PAULO e DAVI.

Estava sozinho na casa quando os policiais entraram acompanhados dos meninos que estavam interessados em comprar a porção de maconha, afirmando que os conhece apenas de vista.

Esclareceu que as drogas ficavam embaixo de uma cama, dentro de uma caixa de papelão, e não soube dizer a quantidade, mas não havia entorpecente exposto, à vista no interior do imóvel.

Narrou que a casa ficava com a porta trancada, mas quando entrou a deixou aberta. A chave ficava embaixo da porta.

Os policiais localizaram maconha e cocaína, mas não soube dizer a quantidade. Por fim, esclareceu que começou a comercializar os entorpecentes pela manhã e no momento da abordagem policial portava quantia em espécie oriunda da traficância, ou seja, entre R\$300,00 e R\$400,00. Afirmou que referida quantia foi encontrada pelos policiais em suas vestes, mas não foi apresentada na delegacia de polícia. Acrescentou que quando chegou na delegacia de polícia os corréus WILTON e EMERSON já estavam no local e todos foram colocados na mesma cela.

Disse que estava arrependido e foi a primeira vez que vendeu drogas.

WILTON ofereceu a surrada versão de que foi abordado e conduzido até a delegacia "para averiguação", passando então a ser acusado injustamente por tráfico de drogas.

Narrou que trabalha em uma tabacaria. Na data dos fatos instalou uma mangueira no referido comércio e "...já tinha uns meninos, umas pessoas sendo abordadas e os policiais me chamou pra fazer parte da abordagem...". Os policiais pediram seus documentos "...Olhou minha bolsinha e viu o dinheiro...".

Entretanto, não portava documentos, e por essa razão foi conduzido para a delegacia de polícia.

Acrescentou que seu genitor se propôs a buscar seus documentos, mas os policiais se recusaram a esperar. Com relação a quantia em dinheiro que portava, disse que era oriunda de seu trabalho na tabacaria.

Por fim, afirmou que os policiais inquiridos em juízo não foram os mesmos que o abordaram.

EMERSON, em síntese, esclareceu que havia acabado de sair de sua residência para entregar uma marmita para o cliente José Augusto. No caminho entrou em um mercado e quando saiu alguns indivíduos estavam sendo abordados por policiais. Na abordagem, "...eles tavam chamando muita gente que tava passando para a abordagem, pegaram e me chamaram para a abordagem, e eu fui para a abordagem também...".

Entretanto, não portava seus documentos pessoais, razão pela qual foi conduzido para delegacia de polícia juntamente com WILTON. Depois de algum tempo - meia hora - os corréus também foram levados ao distrito, e não os conhecia.

Acrescentou que não conhecia as pessoas que estavam sendo abordadas, com exceção de WILTON "...só de vista devido eu fazer umas entregas de marmita para ele, ele era meu cliente...".

Disse que estava trabalhando com entregas de marmita há quinze dias, e nesse período que conheceu o corréu WILTON.

DAVI esclareceu que havia combinado com VICTOR e PAULO um encontro em uma padaria. Foram juntos até uma biqueira para comprar maconha - ideia de VITOR - , pediu a droga ao traficante - KHEDENSOR - que saiu para buscar, e logo depois foram surpreendidos por policiais.

Os policiais os levaram para o interior da casa onde KHEDENSOR havia entrado para buscar a droga.

Portava a quantia de R\$40,00, mas não soube dizer se foi apreendida.

Por fim, disse que trabalha cortando cabelos.

PAULO HENRIQUE, por sua vez, disse que havia marcado um corte de cabelo com DAVI. Marcaram um encontro em uma padaria, VITOR chegou em seguida e depois DAVI.

Saíram juntos e passaram por um ponto de venda de drogas. Pediram uma porção de maconha e o vendedor disse que já não portava a droga e iria buscar. Em seguida foram abordados por policiais civis e levados para o interior de uma casa. Logo que chegaram os policiais lhes mandaram deitar no chão e o vendedor da droga já estava no local.

Afirmou que nunca esteve naquela casa e não chegou a ver drogas no local.

Disse que entregaram o dinheiro ao vendedor "...O Davi deu R\$5,00 e eu dei R\$5,00...", em dinheiro trocado.

VICTOR declarou que pretendia cortar o cabelo no salão de DAVI.

Combinou com PAULO HENRIQUE e DAVI um encontro em uma padaria, às 14 h. Quando chegou PAULO já estava e logo depois chegou DAVI.

Saíram juntos e resolveram comprar uma porção de maconha. Foram até o local onde é realizado o comércio e pediram uma porção de maconha ao traficante. Este, por sua vez, "...falou que não tinha em mãos e que ia buscar...".

Ficaram aguardando e um carro branco se aproximou, quatro indivíduos desembarcaram e passaram a afirmar que "...a casa caiu e que era a gente...". Responderam que estavam comprando, mas foram levados para a casa, outros policiais já estavam no local "...com os meninos deitados no chão...". Não soube dizer se havia drogas no interior do imóvel, afirmando que "...não cheguei a ver...".

"...Eu pedi uma e o DAVI pediu outra...". Portava a quantia de R\$50,00 para pagar a droga, mas não chegou a entregar para o traficante. Referida quantia não foi apreendida e nem mesmo localizada pelos policiais. Disse que não foi revistado no local da abordagem, apenas na delegacia de polícia.

Os policiais lhes determinaram que deitassem no chão, de forma que não presenciou a revista feita no imóvel e nem mesmo a localização de drogas.

Por fim, disse que trabalhava em uma adega, mas não data em que foi preso era seu dia de folga.

Mas referidas exculpatórias foram infirmadas pelo relato seguro dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, não se mostrando mesmo dignas de credibilidade, até porque contraditórias e isoladas nos autos, dissociadas do robusto conjunto probatório, que comprometeu todos os réus.

Assim é que os policiais civis responsáveis pela diligência apresentaram esclarecimentos coerentes e harmônicos a respeito dos fatos.

Informaram que receberam denúncia que havia uma casa invadida na comunidade, conhecida por "casa bomba", que era usada por traficantes para armazenamento de drogas, e que havia alguns indivíduos no referido local trabalhando no tráfico. Passaram essas informações à autoridade, que lhes determinou que fossem verificar. Dirigiram ao endereço apontado, identificaram o imóvel e realizaram campanha de aproximadamente trinta minutos.

Ressaltaram que depois desse período dois indivíduos saíram da casa - WILTON e EMERSON, os abordaram e em poder de um deles localizaram uma quantia em dinheiro, em notas trocadas. Questionados, ambos admitiram que saíram do imóvel, eram "...funcionários do tráfico...", que havia drogas na casa e que o dinheiro que portavam era oriundo da mercancia. Chegaram a afirmar que fizeram uma entrega de drogas na casa.

Seguiram para o imóvel, e logo que entraram localizaram os corréus manipulando grande quantidade de drogas diversificadas, ou seja, estavam separando e embalando os entorpecentes.

Chegaram a afirmar que esses indivíduos estavam até sujos de drogas e parecia uma espécie de "linha de produção".

Disseram que as drogas estavam expostas no imóvel e espalhadas em todos os lugares "...Na mesa, na bancada, na cama, no forno, na geladeira ...", e os réus que as estavam manipulando, cortando.

Ressaltaram que "...era súper visível, qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer ser que entrasse ali veria que era casa bomba...".

Acrescentaram que havia também facas, embalagens, balança, etc.

As testemunhas de defesa não trouxeram qualquer informação que comprometesse a lisura do trabalho policial.

Adilson J. Silva, genitor do réu EMERSON, não presenciou o início da abordagem policial, o que lhe foi comunicado por moradores da região. Dirigiu-se ao local, e quando chegou viu seu filho do outro lado da rua. Após, os policiais lhe informaram que o acusado seria levado para a delegacia para averiguação, juntamente com WILTON, que conhece apenas de vista.

José Augusto L. Urias e Sandy H.B. de Almeida afirmaram que presenciaram a abordagem do acusado EMERSON e de outros indivíduos, e não viram a apreensão de nada ilícito.

Disseram que WILTON estava discutindo com os policiais. Havia outros três indivíduos, que foram liberados.

Lourival G. Da Silva, pai de WILTON, disse que seu filho trabalhava como ajudante de pedreiro e em uma tabacaria, que o ajudou a montar um mês antes da prisão.

Esclareceu que esteve no local e encontrou WILTON nervoso, acompanhado de quatro ou cinco pessoas, porque estava sem documento.

Ficou sabendo que esses indivíduos eram policiais e levaram o acusado para a

delegacia de polícia, a pretexto de averiguação.

Wesley da S. Liberado disse que presenciou quando WILTON foi abordado por policiais. Afirmou que "...onde eu estaciono minha moto é do lado do estacionamento dele...".

Afirmou que reside em uma rua próxima, caminhou para sua residência e viu um veículo descaracterizado e quatro ou cinco rapazes sendo abordados.

Disse que viu quando os policiais conduziram WILTON e outro rapaz para a delegacia, "...Eu acho que era por causa de documento...".

Severino F. Cardoso atestou os bons antecedentes de seu filho DAVI, que trabalha como cabeleireiro. Afirmou que DAVI é usuário de drogas.

Elton C. Gomes atestou os bons antecedentes de PAULO HENRIQUE, que trabalha fazendo bicos em uma marcenaria. Disse que PAULO é usuário de maconha e álcool.

João Chavier da Silva atestou os bons antecedentes do acusado VICTOR, e nada informou sobre o mérito da presente ação penal.

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do delito de tráfico drogas e autoria.

Os réus, ainda no calor da prisão em flagrante, admitiram informalmente aos policiais que eram os responsáveis pela venda de entorpecentes naquele local, pormenorizando a função de cada um.

Em solo policial, quando tiveram a primeira oportunidade de clamar sua inocência, não o fizeram, preferindo o silêncio.

Embora direito constitucional, não é postura compatível com a situação de pessoas inocentes, frente a prisão injusta e graves acusações.

Em Juízo, todos negaram a responsabilidade pelas drogas apreendidas, com exceção de KEDERSON, que tentou convencer que estava vendendo entorpecentes no local em que foi abordado, o que fazia pela primeira vez, justificando que enfrentava dificuldades financeiras. Atribuiu aos corréus DAVI, PAULO HENRIQUE e VICTOR a condição de usuários, afirmando que os atendeu no comércio espúrio em questão, sendo que apenas um deles - VICTOR - lhe pediu uma porção de maconha.

Esclareceu que já não dispunha da referida droga naquele momento, entrou em um imóvel para buscar a maconha, e foi abordado pelos policiais civis.

Disse que o traficante o orientou a respeito do imóvel onde as substâncias eram armazenadas.

Por fim, tentou convencer que WILTON e EMERSON sequer estavam no local, e os encontraram apenas na delegacia de polícia.

Os corréus, por sua vez, seguiram por essa mesma linha, apresentaram singelas negativas de autoria, cuja veracidade nem de longe comprovaram, como lhes cometia fazer.

O teor dos depoimentos prestados pelos réus são comprometedores, uma vez que eivados de contradições, quer com relação a quantia em dinheiro que portavam para comprar a maconha, quer com relação ao pagamento da droga ao vendedor, quer também como relação as porções que teriam pedido.

KHEDENSON afirmou que apenas VICTOR lhe pediu a porção de maconha; ao passo DAVI afirmou que foi o único que pediu a droga ao vendedor; PAULO HENRIQUE esclareceu que pediu uma porção de maconha e DAVI também, cada qual teria entregado a quantia de R\$5,00 ao traficante para pagamento; VICTOR, por sua vez, disse que pediu a droga e DAVID também, e que portava a quantia de R\$50,00 para pagamento, mas que não chegou a entregar o dinheiro ao vendedor.

Ora, os réus KHEDENSON, VICTOR, DAVI e PAULO HENRIQUE não entraram em um acordo a respeito de quantas porções de maconha estavam transacionado, qual deles exatamente as estaria adquirindo, e se efetuaram ou não algum pagamento ao vendedor.

Referidas contradições bem demonstram que faltaram com a verdade.

E nesse aspecto, pelo que informaram, portavam dinheiro, ou seja, KHEDENSON a quantia de R\$300,00 a R\$400,00 da venda das drogas que teria realizado pela manhã, e VICTOR R\$50,00 para pagamento da porção de maconha que estava adquirindo.

Ambos disseram que foram revistados, mas o dinheiro que portavam não foi apreendido pelos policiais. Ora, se de fato portassem dinheiro nas vestes, teria sido apreendido pelos policiais.

No mais, WILTON e EMERSON apresentaram singelas escusas; o primeiro no sentido de

que estava cuidando da tabacaria de sua propriedade, e o segundo que estava saindo de um mercado, a fim de entregar marmita para um cliente - cujos dados de qualificação não informou e não foi arrolado pela Defesa para confirmar essa informação no contraditório.

Entretanto, nenhum dos réus produziu qualquer prova segura a demonstrar a veracidade das exculpatórias que prestaram, como lhes competia fazer, nos termos do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, se verídicas essas versões, não haveria contradição entre elas e não se justifica omitidas em solo policial, perante a autoridade.

Ao contrário, os policiais civis, de forma absolutamente serena, confirmaram que receberam denúncia, apontando o tal imóvel como local conhecido por "casa bomba". Apresentaram essa informação à autoridade, que lhes determinou fossem averiguar.

Dirigiram-se ao endereço apontado, realizaram campanha de aproximadamente meia hora, WILTON e EMERSON saíram da casa, de forma que os abordaram. O primeiro portava a quantia de R\$895,00 em espécie e notas trocadas, e ambos admitiram que haviam acabado de abastecer o local com drogas.

Ingressaram no imóvel e surpreenderam os demais denunciados, todos manipulando e embalando as drogas, em atividade que rotularam como "linha de produção". Havia também embalagem, guilhotina, balança, etc. Segundo informaram os policiais, os réus estavam sujos de drogas.

Deram conta que havia muito entorpecente no local, por todo lado e à vista. Havia também petrechos para armazenamento e embalagem dos entorpecentes.

Na oportunidade, informalmente, todos os réus admitiram e indicaram a função de cada um na atividade criminosa aqui tratada.

Os policiais deram conta que não havia morador no imóvel, e que traficantes costumam invadir esses locais e retirar os habitantes.

Como já dito, nas oportunidades em que foram inquiridos, os policiais apresentaram esclarecimentos coerentes e harmônicos a respeito dos fatos, narrando com detalhes a dinâmica da diligência e confirmando a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes diversificados em poder dos réus.

Logo, não há que se falar em prova precária, o que impede seja acolhida a pretensão absolutória dos Drs. Defensores.

E a versão apresentada pelos policiais é digna de toda credibilidade, uma vez que não existe demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente. Como qualquer outra testemunha, o policial presta compromisso de dizer a verdade e a versão que apresenta só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas". (TJRJ - AC - Rel Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

O destino do tóxico apreendido é manifesto. Os réus portavam expressiva quantidade de drogas diversificadas, mais de dois quilos e meio, ou seja: 01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 926,8g de Cocaína; 48 frascos plásticos contendo, aproximadamente, 96,4g de Tetrahydrocannabinol, na forma de 'Skunk'; 278 microtubos plásticos contendo, aproximadamente, 267,9g de cocaína; 01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 197,5g de cocaína; 01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 125,7g de Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha; 64 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 410,4g de maconha; 1131 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 620,9g de cocaína, e 01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 39,8g de cocaína na forma de 'crack'. As drogas estavam separadas em inúmeras porções individuais, prontas para abastecer um elevado número de usuários, de forma que também não é o caso de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei especial.

Ademais, nem mesmo os réus reivindicaram a posse dos entorpecentes para consumo próprio, o que não se cogita em razão da quantidade significativa apreendida, incompatível com a posse para mero consumo.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de

traficante, uma vez que: "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (TJSP AC 9.751-3 Rel. Gonçalves Sobrinho RJTJSP 75/343).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76." (TJMT AC 565/86 Rel. Mauro José Pereira RT 620/331).

A solução é a mesma com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06. O animus associativo entre os acusados restou bem delineado e demonstrado pelas circunstâncias em que foram presos em flagrante.

Os réus estavam organizados, previamente ajustados, promoviam ativamente e de forma estável e duradoura do esquema de abastecimento, armazenamento, preparo e venda dos entorpecentes.

E a convicção nesse sentido é formada pelos esclarecimentos prestados pelos policiais ouvidos em Juízo, que delinearam com minúcias a função de cada um dos agentes no esquema criminoso em questão. Segundo informaram, WILTON e EMERSON abasteciam o local com as drogas, que eram fracionadas e embaladas por KHEDENSON, DAVI, VICTOR e PAULO HENRIQUE, para posterior distribuição nos pontos de mercancia. A divisão das funções e a logística do armazenamento das drogas e preparo das drogas é manifesta. No dia dos fatos, policiais localizaram inúmeras porções de entorpecentes, boa parte cocaína, bem como embalagens e guilhotina contendo resquícios de maconha, tudo em um imóvel preparado unicamente para referida atividade ilícita, o que não se faz de um dia para outro.

A prova produzida nos autos bem demonstrou a estrutura de que dispunham os acusados para o preparo e armazenamento de drogas, o que pressupõe estabilidade. Logo, os réus compunham equipe organizada e estruturada para o cometimento de tráfico de drogas, o que faziam de forma estável e permanente.

Por esses argumentos, não há que se falar em prova precária, inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória da Defesa.

Demonstrada a ocorrência dos delitos, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Ao que consta, todos os réus são primários, com exceção de EMERSON, que é reincidente - condenação oriunda da 7ª Vara criminal desta capital cujo trânsito em julgado para a defesa se deu em 24/06/19.

Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código penal, fixo a pena-base de cada crime no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa para o tráfico de drogas, e três anos de reclusão e setecentos dias-multa para o crime previsto no artigo 35 da lei 11.343/06.

Incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal, já que os delitos foram praticados durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cabe ressaltar, ademais, que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Basta para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social.

Nesse sentido: "Reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal. Pertinência. Crime cometido durante estado de calamidade pública, reconhecido em razão da pandemia da COVID-19. Circunstância objetiva, que, de qualquer forma, revela maior reprovabilidade da conduta. Provimento." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501177-22.2020.8.26.0616, Relator: Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, DJe em 22/03/2021).

O texto legal é expresso ao estabelecer a incidência da referida circunstância

quando o crime é praticado por ocasião de qualquer calamidade pública, não se exigindo nexo de causalidade.

Os acusados VICTOR, DAVI, PAULO HENRIQUE e KHENDERSON são menores de 21 anos, de forma que referida atenuante fica compensada com a agravante de ter sido o crime praticado por ocasião de calamidade pública.

Agravo as penas aplicadas aos réus WILTON e EMERSON, o primeiro em 1/6, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, e três anos e seis meses de reclusão e oitocentos e dezesseis dias-multa; e o segundo em 1/5, tendo em vista também a reincidência comprovada (duas agravantes), totalizando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, e três anos, sete meses e seis dias de reclusão e oitocentos e quarenta dias-multa (artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, respectivamente).

Não é o caso de aplicar o redutor de pena previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, tendo em vista a quantidade expressiva de drogas que os réus armazenavam em local previamente estruturado e preparado para essa finalidade, ou seja : 01 invólucro plástico, contendo, aproximadamente, 926,8g de Cocaína; 48 frascos plásticos contendo, aproximadamente, 96,4g de Tetrahydrocannabinol, na forma de 'Skunk'; 278 microtubos plásticos contendo, aproximadamente, 267,9g de cocaína; 01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 197,5g de cocaína; 01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 125,7g de Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha; 64 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 410,4g de maconha; 1131 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 620,9g de cocaína, e 01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 39,8g de cocaína na forma de 'crack'. o que faziam de maneira bastante estruturada, revelando o risco extremo que oferecem à saúde pública, já que responsáveis pelo armazenamento e entrega a terceiros de substâncias altamente nocivas e viciantes, que provocam consequências graves aos viciados, às famílias e à sociedade.

De se considerar que o redutor de pena não tem aplicação quando demonstrada estabilidade criminosa, por estar ausente o requisito "não se dedicar a atividade criminosa". As circunstâncias do flagrante bem demonstraram que, pela quantidade expressiva de drogas que armazenavam, vinham comercializando entorpecentes já havia muito tempo, abasteciam os pequenos traficantes e os pequenos pontos de venda de drogas, o que demonstra que não são criminosos ocasionais, mas habituados à atividade criminosa em questão.

Nesse sentido: "PENA - Fixação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Federal n. 11343/06 - Inviabilidade - Agente surpreendido quando trazia consigo 59 porções de maconha e 11 de cocaína - Quantidade de drogas apreendidas indicadora de que o réu faz do tráfico seu meio de vida, ou seja, de que se dedica à atividade criminosa, não sendo, portanto, merecedor da redução da reprimenda - Recurso da defesa improvido, sendo dado parcial provimento ao ministerial para elevar as penas impostas". (Apelação Criminal n. 990.09.081797-6 São Paulo 9ª Câmara de Direito Criminal Relator: Souza Nery 01.10.09 V.U. Voto n. 15796).

Considerando o concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal, uma vez que as infrações penais são autônomas e resultantes de desígnios independentes, as penas devem ser somadas, restando, em final dosimetria para VICTOR, DAVI, PAULO e KHENDERSON em oito anos de reclusão e mil e duzentos dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal; para WILTON em nove anos e quatro meses de reclusão e mil e quatrocentos dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal; e EMERSON em nove anos, sete meses e seis dias de reclusão e mil, quatrocentos e quarenta dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra EMERSON DA SILVA, R.G. nº 43.572.668, WILTON SANTOS DE LIMA, R.G. nº 50.551.278, VICTOR MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA, R.G. nº 53.736.549, DAVI TEODORO CARDOSO, R.G. nº 55.735.922, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, R.G. nº 55.619.772, e KHENDERSON HENRIQUE ROQUE HONORIO, R.G. nº 52.372.015, e os condeno, o primeiro - EMERSON - ao cumprimento de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a mil, quatrocentos e quarenta dias-multa, o

segundo - WILTON - ao cumprimento de nove anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a mil e quatrocentos dias-multa; e os demais - VICTOR, DAVI, PAULO HENRIQUE e KHEDENSON, cada um, ao cumprimento de oito anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a mil e duzentos dias-multa, todos por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da lei 11.343/06, c.c. artigo 69 do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista o que dispõe a Lei 11.464/07 que alterou a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º da lei 8.072/90.

Tendo em vista a gravidade dos crimes aqui tratados, o tráfico considerado hediondo, para garantia da ordem pública os acusados NÃO poderão recorrer em liberdade, deverão ser recomendados na prisão em que se encontram e, igualmente, não preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação aos crimes tratados na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais. O tráfico é crime hediondo, que compromete a saúde pública, e a medida não se mostra socialmente recomendável.

Nesse sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena - Cabimento - Materialidade e autoria comprovadas - 45 (quarenta e cinco) microtubos plásticos encontrados no exato local em que o réu se abaixou, próximo de sua carteira que também foi dispensado pelo Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Pena-base fixada acima do mínimo legal, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu - Aplicação da agravante da reincidência - Não aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Substituição por restritivas de direitos - Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO PROVIDO" (TJ-SP; Apelação nº 0001725-63.2017.8.26.0540; Relator(a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019). "ENTORPECENTE. Tráfico. Desclassificação em primeiro grau para o delito de posse de tóxico para uso pessoal. Recurso ministerial buscando a condenação pelo crime de tráfico. Circunstâncias da abordagem e quantidade de entorpecente apreendido indicando destinação comercial, segundo os critérios do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Condenação por tráfico que se impõe. Dosimetria. Básicas que partem dos mínimos legais, sendo acrescidas de um quinto, na segunda fase, pela dupla reincidência, a qual, aliás, impede a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Regime fechado necessário, sendo incogitável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Apelo ministerial provido, com determinação" (TJ-SP; Apelação nº 0004107-35.2017.8.26.0635; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

Persistem as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, reforçadas pelas provas produzidas na presente ação penal, que bem demonstraram a responsabilidade deles por ambos os crimes denunciados, medida que fica aqui mantida, o que se faz necessário para se resguardar a ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal.

Em cumprimento ao que estabelece o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, por ser medida necessária, mantenho a prisão preventiva dos acusados, já que mostram-se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nos termos do que dispõe os artigos 60 e seguintes da Lei 11.343/06 e 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, determino a perda em favor da União da quantia em dinheiro apreendida em poder de WILTON, relacionada no auto de exibição e apreensão - R\$895,00 - cuja procedência lícita não foi comprovada, uma vez que oriunda do comércio espúrio aqui tratado.

Condeno os acusados ao pagamento das custas do processo, nos termos do que

estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados. Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, em complementação às informações prestadas em habeas corpus (págs. 627/628).

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de maio de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA